

1516209-33.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516209-33.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516209-33.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179938/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 18859190 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 3164/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2179938 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO DA SILVA MARCELINO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

ROGÉRIO DA SILVA MARCELINO, qualificado a fls. 14/15, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (em ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque na manhã de 4 de julho de 2021, por volta das 10h20, na Rua Lucilo Varejão nº 18, Cidade Dutra, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo consigo, em ocasião de calamidade pública, para o tráfico de drogas, 70 (setenta) microtubos plásticos contendo cocaína, 37 (trinta e sete) porções de maconha e 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína na forma de crack.

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2021 (fls. 61/63).

Pessoalmente notificado (fl. 78/80), o acusado apresentou defesa prévia (fl. 90).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas. Não tendo sido o réu localizado (fl. 115) no endereço por ele informado (fls. 80), foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais oralmente, conforme gravação audiovisual.

O d. Representante do Ministério Público, pugnou pela procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia.

A i. Defesa, por sua vez, sustentou pela improcedência da pretensão punitiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no patamar mínimo legal, o afastamento da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, e a aplicação do redutor do artigo 33, §4º, LD. Ainda, pleiteou a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa vem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls. 23/26, indicador de que o acusado trazia consigo a quantia de R\$254,00 (duzentos e cinquenta e quatro reais), além de 70 (setenta) porções de cocaína, com massa líquida de 44,8g (quarenta e quatro gramas e oito decigramas), 37 (trinta e sete) porções de maconha, com massa líquida de 79,6g (setenta e nove gramas e seis decigramas) e 36 (trinta e seis) pedras de crack, com massa líquida de 9,8 (nove gramas e oito decigramas). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 97/99, está comprovado que a substância apreendida com o acusado era "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil" e "tetrahydrocannabinol (THC), constante na Lista F2".

Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida em juízo, a testemunha policial militar Otavio Henrique Bevilacqua Aguiar Silva relatou que estava em patrulhamento de rotina pela rua Luciano Varejão, que é local bastante conhecido pelo tráfico de drogas. Explicou que essa rua tem uma viela muito estreita, que dá acesso a um conjunto habitacional. Durante o patrulhamento, identificou um indivíduo em atitude suspeita. Ao avistar a equipe policial, o acusado tentou se evadir, mas não conseguiu, pois os policiais já estavam muito perto. Na abordagem, foi localizada quantia em dinheiro nos bolsos de trás e, nas suas vestes, foi localizado um estojo contendo entorpecentes variados. Disse que foi o responsável pela revista pessoal, ao passo que seu companheiro fez a entrevista.

No mesmo sentido, o depoimento em juízo da testemunha policial militar Renato Ernesto Mariano Oliveira, que relatou que estava em patrulhamento em motocicleta com seu parceiro, quando adentraram em local já conhecido como ponto de venda de drogas. O réu estava no local e, ao avistar a equipe, tentou se evadir. Fizeram a abordagem e, com ele, localizaram dinheiro e as drogas. Durante a entrevista, o acusado admitiu que estava traficando havia um ano e sua função era recolher o dinheiro e entregar os pacotes na biqueira para venda.

Na Delegacia, o réu negou que estivesse traficando, acrescentando que, com ele, fora encontrado apenas o dinheiro.

Por seu turno, não se interessou em comparecer em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia.

Como visto, a prova produzida pela acusação autoriza a condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes, não tendo o réu se desincumbido de trazer aos

autos qualquer prova apta a infirmar os robustos depoimentos das testemunhas no sentido de que foram encontradas drogas, além de dinheiro em espécie, na posse do denunciado.

Com efeito, esclareceram os policiais que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu em local conhecido pela venda de substâncias entorpecentes. Durante a abordagem, ao submetê-lo à busca pessoal, localizaram no interior de um estojo dentro de suas vestes diversas porções de cocaína, maconha e crack, embaladas em forma própria para venda.

Indagado, o acusado confessou informalmente a prática do crime, detalhando, inclusive suas funções de recolher o dinheiro e abastecer os pontos de venda, com os pacotes de drogas.

Saliente-se, ainda, que diante das condições em que encontradas as drogas, especialmente da quantidade, variedade e notadamente da forma como acondicionadas, vale dizer, em porções individuais, certo é que serviriam à entrega e ao consumo de terceiros.

Nessa medida, ainda que o acusado não tenha sido flagrado durante a efetiva entrega de entorpecentes a terceiros, deve ser condenado nos termos da imputação inicial, a ressaltar que "para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

É o que basta à condenação, dada a robustez, coerência e firmeza da prova amealhada aos autos.

De outro lado, a alegação da d. Defesa quanto à insuficiência do depoimento dos policiais para fundamentar condenação, dado o interesse que teriam em confirmar suas ações constitui-se em mera presunção, destituída de amparo jurídico. Policiais não são impedidos de depor e nem são considerados, de per si, suspeitos, sendo certo que seus depoimentos hão de ser dignos de fé quando acompanhados de outros elementos de prova - estes aqui existentes, ante as provas pericial e documental juntadas, laudo e auto de apreensão - quando prestados em uníssono, com coerência e plena segurança, sendo esta a hipótese dos autos.

Quanto à relevância dos depoimentos dos policiais, o entendimento dominante nos Tribunais, confira-se:

"(...) Com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com a qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...)" (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017).

No caso dos autos, não se vislumbra nenhum abuso por parte dos policiais, sendo cioso notar que restou incontroverso que os policiais e o réu não se conheciam anteriormente aos fatos, pelo que suas declarações merecem credibilidade.

Portanto, a conduta delitativa praticada pelo réu se adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sendo de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu é tecnicamente primário (fl. 28/30). As demais circunstâncias judiciais são neutras, razão pela qual fixo a

pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a considerar. De outra parte, muito embora o crime realmente tenha sido praticado quando em vigor situação de calamidade assim reconhecida pelo poder público, decorrente da pandemia da doença provocada pelo corona vírus, não se observa que essa circunstância tenha sido algo relevante na prática do delito ou mesmo que da conduta tenha resultado algum efeito sobre a situação calamitosa. Tratando-se, no caso, de circunstância meramente accidental, que não propiciou facilidade para a prática criminosa e nem tampouco foi impactada pela conduta do réu, não justifica o agravamento da punição. Assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento 500 (quinhentos) dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistem causas de aumento. Por outro lado, aplico o redutor inscrito no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O réu é tecnicamente primário e não há provas de que integra, de fato, organização criminosa. Entretanto, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas com o acusado, mormente as sete dezenas de porções de cocaína e quase quatro dezenas de porções de crack, tenho que as margens legais do redutor previsto no artigo 33, §4º, LD devem ser adequadamente sopesadas, tendo em vista o elevado potencial danoso da conduta do acusado, com grande quantidade de drogas, com notório poder viciante e consequências severas aos seus usuários. A respeito da possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria da pena, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena." (HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022). Portanto, a pena deve ser reduzida em 1/2 (metade), definindo a pena final em terceira fase em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

À míngua de outros elementos, é de rigor a fixação do mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato.

A Resolução nº 5/12 do Senado Federal suspendeu a execução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na parte em que vedava a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Nessa medida, verifico a possibilidade da aplicação do artigo 44 do Código Penal, nos termos dos incisos II e III, pois a culpabilidade e os antecedentes, bem como as circunstâncias do delito indicam que a substituição é suficiente ao réu. Faz jus, portanto, à substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas penas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: a prestação de serviços à comunidade ou à entidade cadastrada pelo Juízo, pelo prazo da pena cominada, e a limitação de fim de semana, nas condições a serem definidas pelo Juízo da Execução. Em caso de descumprimento da pena substituída, fixo o regime inicial aberto.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público contida na denúncia para CONDENAR ROGÉRIO DA SILVA MARCELINO, qualificado a fls. 14/15, como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo previsto na pena substituída e limitação de fim de semana, sendo que o local e modo de cumprimento serão indicados pelo D. Juízo das Execuções.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesp, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Encerrada a instrução e substituída a pena corporal por restritiva de direitos,

concedo ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado para dar início ao cumprimento das penas.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

São Paulo, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA